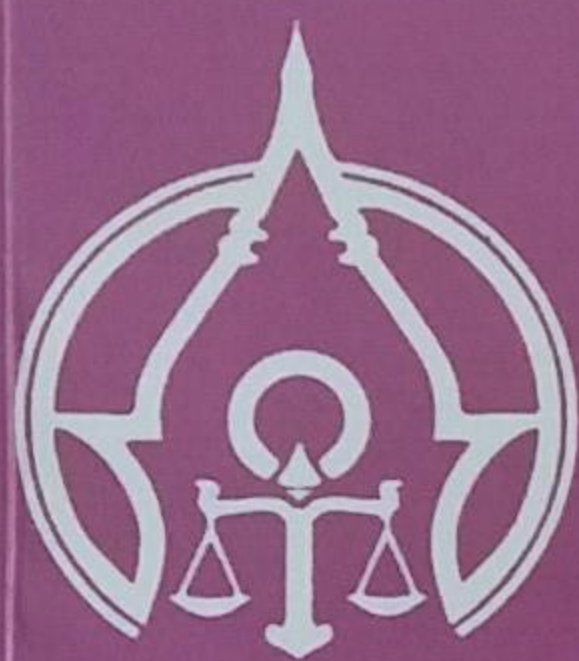


วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1

มิถุนายน 2555

✧ บทความทั่วไป

- การวิเคราะห์และเปรียบเทียบสาระสำคัญของข้อบทความตกลงทางด้านการลงทุน
- Concept of Intellectual Property Rights and the Protection of Traditional Medicines Derived from Plants
- ความสับสนของการใช้คำในกฎหมาย 1) “โมฆะ” “โมฆียะ” “ไม่สมบูรณ์” “ไม่บริบูรณ์” และ “ไม่ผูกพัน”
- การลงลายมือชื่อมีความสำคัญในทางกฎหมายอย่างไร
- ความยุติธรรมคืออะไร ?
- Problems and Solutions of Orphan Works in Digital Access
- นวัตกรรมสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมกับกฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Innovation Communication for Social Development Law and Ethic

✧ แนะนำกฎหมายใหม่

✧ ฎีกาวิเคราะห์

✧ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ
ชุดวิชา



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อังครัต ดลเจิม

คำถาม

นางสาวสายสมรและนางสาวสายน้ำ เป็นเพื่อนกัน นางสาวสายสมรเคยขอยืมสร้อยเพชรจากนางสาวสายน้ำ ไปสวมใส่บ่อยๆ วันหนึ่ง นางสาวสายสมรจะไปดูงานที่ประเทศอิตาลีนาน 1 เดือน จึงพูดขอยืมเช่นเดิม นางสาวสายน้ำ รู้สึกรำคาญที่นางสาวสายสมรขอยืมบ่อยๆ จึงบอกขายสร้อยเพชรแก่นางสาวสายสมรเป็นเงิน 200,000 บาท และส่งมอบสร้อยเพชรให้ นางสาวสายสมรไป โดยคิดว่า นางสาวสายสมรตกลงซื้อสร้อยเพชรดังกล่าว นางสาวสายสมรก็รับสร้อยเพชรไปโดยคิดว่า นางสาวสายน้ำให้ยืม ต่อมาเมื่อนางสาวสายสมรกลับจากประเทศอิตาลีแล้ว นางสาวสายน้ำจึงทวงเงินค่าสร้อยเพชรจากนางสาวสายสมร นางสาวสายสมรแย้งว่า ยืมสร้อยเพชรไม่ใช่ซื้อ นางสาวสายน้ำคัดค้านว่า นางสาวสายน้ำตกลงขายให้นางสาวสายสมรต่างหาก ไม่ใช่ยืมอย่างเคยนางสาวสายสมรต้องชำระค่าสร้อยเพชรให้แก่ตน เช่นนี้ ข้ออ้างของนางสาวสายน้ำฟังขึ้นหรือไม่

แนวตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 156 บัญญัติว่า

“การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม เป็นโมฆะ

ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม และความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น”

กรณีตามข้อเท็จจริงนี้ เป็นเรื่องการแสดงเจตนาทำนิติกรรมโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมจากบทบัญญัติในป.พ.พ. มาตรา 156 นี้ สามารถแยกประเภทของความผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของนิติกรรมได้ 3 ลักษณะ คือ ความสำคัญผิดในลักษณะแห่งนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในตัวทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม กรณีตามปัญหานี้เป็นความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ซึ่งเป็นผลทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ เพราะฝ่ายนางสาวสายสมรรับสร้อยเพชรไปโดยสำคัญผิดโดยคิดว่า นางสาวสายน้ำให้ยืม ส่วนนางสาวสายน้ำส่งมอบสร้อยเพชรให้ นางสาวสายสมรไปโดยสำคัญผิดคิดว่า นางสาวสายสมรซื้อสร้อยเพชรตน ดังนั้นต่างฝ่ายต่างสำคัญผิดในนิติกรรมโดยเป็นการสำคัญผิดในประเภทของนิติกรรมคือทำนิติกรรมไปผิดประเภทที่ตนประสงค์จะทำขึ้น ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 156 เช่นนี้ ข้ออ้างของนางสาวสายน้ำจึงฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องการแสดงเจตนาทำนิติกรรมโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะตามป.พ.พ. มาตรา 156

จากโจทย์การที่นางสาวสายสมรรับสร้อยเพชรไปโดยสำคัญผิดโดยคิดว่า นางสาวสายน้ำให้ยืม ส่วนนางสาวสายน้ำส่งมอบสร้อยเพชรให้ นางสาวสายสมรไปโดยสำคัญผิดคิดว่า นางสาวสายสมรซื้อสร้อยเพชรตนนั้นจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายต่างสำคัญผิดในนิติกรรมโดยเป็นการสำคัญผิดในลักษณะแห่งนิติกรรมซึ่งเป็นการสำคัญผิดในประเภทของนิติกรรมคือทำนิติกรรมไปผิดประเภทที่ตนประสงค์จะทำขึ้น ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะตามมาตรา 156

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดโดยวินิจฉัยว่าเป็นการแสดงเจตนาซ่อนเร้น ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดเพราะการแสดงเจตนาซ่อนเร้นกับการแสดงเจตนาสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมมีข้อแตกต่างกัน คือ การแสดงเจตนาซ่อนเร้นนั้นเป็นการแสดงเจตนาออกมาโดยผู้ที่แสดงเจตนาอยู่แล้วว่าเจตนาที่ตนแสดงออกมานั้นไม่ตรงกับเจตนาแท้จริงในใจของตน แต่เป็นกรณีที่ผู้แสดงเจตนาแกล้งแสดงเจตนาออกมาให้ผิดไปจากเจตนาที่แท้จริงในใจของตน อันเป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 154 แต่การแสดงเจตนาสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญตามปัญหานี้เป็นการแสดงเจตนาออกมาโดยผู้ที่แสดงเจตนาเห็นว่าเจตนาที่ตนแสดงออกมามีตรงกับเจตนาแท้จริงในใจของตน แต่ปรากฏว่าเจตนาที่ตนแสดงออกมานั้นกลับไม่ตรงกับเจตนาแท้จริงในใจซึ่งเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิด ดังนั้นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นและการแสดงเจตนาสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญจึงมีความแตกต่างกันตรงที่ว่า ผู้แสดงเจตนาที่รู้หรือไม่ว่า เจตนาที่ตนแสดงออกมานั้นตรงกับเจตนาที่แท้จริงในใจหรือไม่ ถ้ารู้หรือไม่ตรง แต่แกล้งแสดงออกให้ผิดไปจากเจตนาที่แท้จริง ก็เป็นเรื่องเจตนาซ่อนเร้นซึ่งตามปัญหานี้ทั้งสายสมรและสายน้ำต่างไม่รู้และไม่ได้แกล้งให้ผิดไปจากเจตนาที่แท้จริง จึงเข้ากรณีไม่รู้ว่าจะไม่ตรงกับเจตนาที่แสดงออกมาจึงเป็นเรื่องการแสดงเจตนาสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญไม่ใช่การแสดงเจตนาซ่อนเร้น



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ชัดเงางาม

คำถาม

นายสมชายว่าจ้างให้นายสมศักดิ์สร้างบ้านบนที่ดินของตนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีที่ดินติดกับตึกของนางสมศรี สมชายสั่งให้สมศักดิ์สร้างบ้านโดยมีแนวบ้านติดกับแนวเขตของตึกของสมศรี ซึ่งสมศักดิ์ได้เตือนสมชายแล้วว่า หากมีการตอกเสาเข็มอาจจะเหวี่ยงถึงตึกของนางสมศรีได้ แต่เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงมาก และสมชายต้องการให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากจึงไม่ฟังคำเตือนของนายสมศักดิ์ สมศักดิ์จึงดำเนินการตามคำสั่งของนายสมชาย ทำให้ตึกของนางสมศรีเกิดรอยร้าวเป็นทางยาวกว่า 15 เมตร เนื่องจากการตอกเสาเข็มของนายสมศักดิ์

ดังนี้ นางสมศรีจะฟ้องร้องนายสมชาย หรือนายสมศักดิ์ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ตนได้หรือไม่อย่างไร

แนวตอบ

มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

มาตรา 428 บัญญัติว่า “ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้น แก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง”

อธิบาย

โดยหลักทั่วไปของความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของต่อบุคคลภายนอกในการกระทำอันเป็นละเมิดนั้น ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องรับผิดกับผู้รับจ้าง แต่กรณีจากโจทย์ นายสมชายผู้ว่าจ้างสั่งให้นายสมศักดิ์ผู้รับจ้างกระทำการตามที่ตนต้องการ ทั้งที่นายสมศักดิ์ได้เตือนนายสมชายแล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านข้างเคียงได้ ถือได้ว่าเป็นการงานที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในส่วนงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนได้ให้ไว้ นายสมชายผู้ว่าจ้างจะต้องร่วมรับผิดกับนายสมศักดิ์ผู้รับจ้างฐานที่ได้กระทำละเมิดต่อนางสมศรี

สรุป นางสมศรีสามารถฟ้องนายสมศักดิ์และนายสมชายให้ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายฐานละเมิดต่อตนได้

ข้อสังเกต : มีนักศึกษาจำนวนมากตอบว่านางสมศรีสามารถฟ้องนายสมชายได้เพียงคนเดียว เนื่องจากเป็นผู้สั่งให้นายสมศักดิ์ผู้รับจ้างเป็นผู้กระทำการโดยลืมนำมาตรา 428 เป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดชอบผู้รับจ้างในการทำงานที่ตนสั่งให้ทำ และประเด็นที่โจทย์ถามก็คือนางสมศรีจะฟ้องร้องใครได้บ้าง มิได้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายสมชายกับนายสมศักดิ์ว่าจะไปไล่เบี้ยกันได้อย่างไรได้ มีนักศึกษาจำนวนมากตอบข้อสอบนอกเหนือจากที่โจทย์ถาม ซึ่งจะทำให้ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้



กฎหมายอาญา 1 : ภาศบทบัญญัติทั่วไป

รองศาสตราจารย์ จิตรา เพียรล้ำเลิศ

คำถาม

1. อานนท์เป็นคนเกลียดแมว วันหนึ่งอานนท์เห็นแมวจรจัดนอนเล่นอยู่บนกระโปรงหน้ารถของสมศักดิ์ซึ่งจอดอยู่หน้าบ้าน อานนท์จึงคว้าก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นขว้างไปที่แมวตัวนั้น ปรากฏว่าก้อนหินไม่ถูกแมว แต่กลับไปโดนกระจกหน้ารถของสมศักดิ์แตกกระจาย สมศักดิ์เจ้าของรถจึงแจ้งความขอให้เสียหาย แต่อานนท์อ้างว่าตนเจตนาขว้างก้อนหินใส่แมวเท่านั้น แต่พลาดไปโดนกระจกตัวเอง ตนมิได้มีเจตนาขว้างให้โดนกระจกรถเลย ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของอานนท์หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วางหลักไว้ว่า บุคคลจะต้องรับผิดชอบในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา.....

กระทำโดยเจตนา ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

ทั้งนี้ “เจตนาเล็งเห็นผล” นั้น หมายถึง เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้

ตามปัญหา การที่อานนท์คว้าก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นขว้างไปที่แมวซึ่งนอนอยู่บนกระโปรงรถของสมศักดิ์นั้น แม้ว่าอานนท์จะมีได้ประสงค์ต่อผลกล่าวคือ มิได้มุ่งหมายให้รถของสมศักดิ์เสียหาย แต่อานนท์ยอมเล็งเห็นได้ว่า การขว้างก้อนหินขนาดใหญ่เท่ากำปั้นไปดังกล่าวย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่รถของสมศักดิ์ได้ จึงเป็นเจตนาโดยเล็งเห็นผล และเมื่อการกระทำของอานนท์เป็นเหตุให้กระจกหน้ารถของสมศักดิ์แตกเสียหาย อานนท์จึงต้องรับผิดชอบทำให้เสียหายโดยเจตนาเล็งเห็นผล

สรุป ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของอานนท์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

สำหรับคำถามข้อนี้พบว่า มีนักศึกษาบางส่วนตอบคำถามโดยมีข้อผิดพลาดบางประการ คือ

1. นักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยว่า เป็นการทำให้เสียหายโดยพลาด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เนื่องจากตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่อานนท์ยอมเล็งเห็นได้ว่า การกระทำ

ของตนเช่นนั้นจะทำให้เกิดผลคือ ความเสียหายแก่รถของสมศักดิ์ได้อย่างแน่นอน จึงเป็นการทำให้เสียหายโดยเจตนาเล็งเห็นผลซึ่งเป็นเจตนาตามความเป็นจริง มิใช่การทำให้เสียหายโดยพลาดซึ่งเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายเช่นที่นักศึกษาเข้าใจ

2. นักศึกษาจำนวนหนึ่งวินิจฉัยว่า อานนท์มิได้มีเจตนาทำให้ทรัพย์สินคือรถของสมศักดิ์เสียหายแต่วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของสมศักดิ์เสียหาย ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะเหตุว่า การกระทำโดยประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ นั้น มีหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นว่า ต้องเป็นการกระทำ ความผิดซึ่ง “มิใช่โดยเจตนา” ซึ่งหมายความว่า จะต้องไม่มีเจตนาไม่ว่าประสงค์ต่อผลหรือย่อมนเล็งเห็นผลแต่ข้อเท็จจริงตามโจทก์ แม้อานนท์มิได้มีเจตนาประสงค์ต่อผลกล่าวคือ มิได้มุ่งหมายต่อผลคือความเสียหายแก่รถของสมศักดิ์ กระนั้นก็ตามอานนท์ย่อมเล็งเห็นได้ว่าการกระทำของตนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถของสมศักดิ์ได้อย่างแน่นอน จึงเป็นการทำให้เสียหายโดยเจตนาเล็งเห็นผล มิใช่การกระทำโดยประมาท

อีกทั้งนอกจากการกระทำของอานนท์จะมีใช้การกระทำโดยประมาทดังได้กล่าวแล้ว การที่นักศึกษาวินิจฉัยว่าอานนท์ต้องรับผิดชอบทำให้เสียหายโดยประมาท ก็ยังเป็นความเข้าใจหลักกฎหมายผิดพลาดไปอีกส่วนหนึ่งด้วย เนื่องจากตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคหนึ่งวางหลักว่า..... บุคคลจะต้องรับผิดชอบในการกระทำโดยประมาท ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดชอบเมื่อได้กระทำโดยประมาท แต่การกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เสียหายนั้นประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติให้ต้องรับผิดชอบทางอาญาแต่อย่างใด



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นางเดือนหึ่งหวนางสาวฟ้าที่มาเป็นเมียน้อยของสามีตนและคิดจะสั่งสอนให้รู้สำนึก นางเดือนจึงใช้กำลังกายเตะถีบและทุบตีนางสาวฟ้า โดยไม่รู้ว่านางสาวฟ้าตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน เพราะนางสาวฟ้าใส่เสื้อตัวใหญ่ หลวม ๆ ทารกในครรภ์ของนางสาวฟ้าคลอดออกมาก่อนกำหนดและมีชีวิตอยู่ได้ 3 นาทีก็ถึงแก่ความตาย ส่วนนางสาวฟ้ามีบาดแผลถลอกตามร่างกายฟกช้ำดำเขียวไปทั้งตัว ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 20 วัน จึงหายเป็นปกติ ดังนี้ นางเดือนต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 295) บัญญัติว่า “ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นางเดือนหึ่งหวนางสาวฟ้าจึงใช้กำลังกายเตะถีบและทุบตีนางสาวฟ้า โดยไม่รู้ว่านางสาวฟ้าตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน เพราะนางสาวฟ้าใส่เสื้อตัวใหญ่ หลวม ๆ แสดงให้เห็นว่านางเดือนไม่มีเจตนาทำให้นางสาวฟ้าแท้งลูก และการที่ทารกคลอดออกมาก่อนกำหนดและมีชีวิตอยู่ได้ 3 นาที ก็ไม่ถือว่าแท้ง แต่การใช้กำลังประทุษร้ายของนางเดือนทำให้นางสาวฟ้าได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลถลอกตามร่างกายฟกช้ำดำเขียวไปทั้งตัว ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 20 วันจึงหายเป็นปกติ ถือว่านางเดือนได้ทำร้ายนางสาวฟ้าซึ่งเป็นผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายของนางสาวฟ้าแล้ว

ดังนั้น นางเดือนจึงต้องรับผิดทางอาญาด้านทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น ตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ต้องการวัดความรู้นักศึกษาในความผิดเกี่ยวกับทำแท้งและความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ถ้านักศึกษาไม่อ่านหนังสือก็จะไม่มีความเข้าใจและตอบข้อสอบข้อนี้ผิด ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบข้อนี้ไม่ยากเลย ในความผิดฐานทำแท้ง ผู้ที่จะมีความผิดฐานนี้ได้จะต้องมีเจตนาทำแท้ง กล่าวคือต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าหญิงที่ตนกระทำนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่ และได้ลงมือทำแท้งแล้ว แต่ตามข้อสอบข้อนี้โจทย์บอกชัดเจนว่านางเดือนไม่รู้ว่า

นางสาวฟ้าตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน เพราะนางสาวฟ้าใส่เสื้อตัวใหญ่หลวม ๆ เมื่อนางเดือนไม่รู้เช่นนั้นนางเดือนจึงไม่มีเจตนาทำแท้ง จึงจะนำเอาความผิดฐานทำแท้งมาปรับใช้กับนางเดือนไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นความผิดสำเร็จหรือพยายามทำแท้งตามที่นักศึกษาหลายคนตอบถูกว่านางเดือนมีเจตนาทำร้ายร่างกาย แต่การทำร้ายร่างกายที่มีทั้งความผิดฐานทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา 295 และความผิดฐานทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 ซึ่งเป็นประเด็นที่ข้อสอบข้อนี้ต้องการวัดความรู้นักศึกษา สำหรับคนที่ตอบว่าเป็นความผิดฐานทำร้ายให้ได้รับอันตรายสาหัสก็เพราะนักศึกษาไปเข้าใจว่าการที่นางเดือนกระทำต่อนางสาวฟ้าจนทารกคลอดออกมาก่อนกำหนดและมีชีวิตอยู่ได้ 3 นาทีก็ตาย เป็นการที่นางเดือนทำแท้งจึงตอบว่านางเดือนผิดตามมาตรา 297 (5) ซึ่งไม่ถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่านางเดือนไม่มีเจตนาทำแท้งและเด็กก็ไม่ตายก่อนคลอดด้วย อีกประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาตอบตามมาตรา 297 (8) เพราะไปจำตัวบทผิด ซึ่งตัวบทมาตรา 297 (8) ต้องเป็นการเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน แต่ตามข้อเท็จจริงในโจทย์นางสาวฟ้านอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานเพียง 20 วันไม่ใช่เกินกว่า 20 วัน จึงไม่เข้ากรณีมาตรา 297 (8)

สำหรับคนที่ตอบตามมาตรา 295 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะนางสาวฟ้าเพียงแต่บาดเจ็บทางร่างกายธรรมดาเท่านั้น

ดังนั้น ถ้านักศึกษาอ่านหนังสือมาดี นักศึกษาก็จะเข้าใจองค์ประกอบของความผิดฐานต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ และจะสามารถตอบข้อสอบได้ถูกต้อง ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบครั้งต่อไปนะคะ



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน ตัวเงิน

รองศาสตราจารย์ เพชรา จารุสกุล

คำถาม

นาริออกตั๋วแลกเงินสั่งให้มานพจ่ายเงินให้สุชาดาเป็นเงิน 200,000 บาท โดยขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออกสุชาดาสลักหลังและส่งมอบตั๋วแลกเงินให้สุธีเพื่อใช้หนี้ ต่อมาสุธีสลักหลังตั๋วฉบับนั้นให้สมหวัง ก่อนที่สุธีส่งมอบตั๋วให้สมหวัง สันหัดเพื่อนสุธีมาลงลายมือชื่อหน้าตั๋ว สุธีจึงได้มอบตั๋วให้สมหวัง เมื่อตั๋วถึงกำหนดสมหวังนำตั๋วไปยื่นให้มานพรับรอง มานพรับรองให้ ใครต้องรับผิดชอบตามตั๋วฉบับนี้บ้าง

แนวคำตอบ

ปพพ.

มาตรา 904 บัญญัติว่า “อันผู้ทรงหนี้ หมายความว่า บุคคลผู้มีตัวเงินไว้ในครอบครอง โดยฐานเป็นผู้รับเงิน หรือเป็นผู้รับสลักหลัง ถ้าและเป็นตัวเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ๆ ก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน”

มาตรา 914 บัญญัติว่า “บุคคลผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลังตั๋วแลกเงินย่อมเป็นอันสัญญาว่า เมื่อตัวนั้นได้นำยื่นโดยชอบแล้วจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตั๋ว ถ้าและตั๋วแลกเงินนั้นเขาไม่เชื่อถือโดยไม่ยอมรับรองก็ดี หรือไม่ยอมจ่ายเงินก็ดี ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังก็จะใช้เงินแก่ผู้ทรง หรือแก่ผู้สลักหลังคนหลัง ซึ่งต้องถูกบังคับให้ใช้เงินตามตัวนั้น ถ้าหากว่าได้ทำถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินนั้นแล้ว”

มาตรา 917 บัญญัติว่า “อันตั๋วแลกเงินทุกฉบับ ถึงแม้ว่าจะมิใช่สั่งจ่ายให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งก็ตาม ท่านว่าย่อมโอนให้กันได้ด้วยสลักหลังและส่งมอบ”

มาตรา 920 บัญญัติว่า “อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตั๋วแลกเงิน”

มาตรา 937 บัญญัติว่า “ผู้จ่ายได้ทำการรับรองตั๋วแลกเงินแล้วย่อมต้องผูกพันในอันจะจ่ายเงินจำนวนที่รับรองตามเนื้อความแห่งคำรับรองของตน”

มาตรา 938 วรรค 2 บัญญัติว่า “อันอาวัลนั้นบุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้รับ หรือแม้คู่สัญญาแห่งตัวเงินนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับก็ได้”

มาตรา 939 บัญญัติว่า “อันการรับอาวัลยอมทำให้กันด้วยเขียนลงในตัวเงินนั่นเอง หรือที่ใบประจำต่อ

ในการนี้พึงใช้ถ้อยคำสำนวนว่า “ใช้ได้เป็นอาวัล” หรือสำนวนอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อผู้รับอาวัล

อนึ่ง เพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวัลในด้านหน้าแห่งตัวเงิน ท่านก็จัดว่าเป็นคำรับอาวัลแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่เปลี่ยนมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้ส่งจ่าย

ในคำรับอาวัลต้องระบุว่ารับประกันผู้ใด หากมิได้ระบุ ท่านให้ถือว่ารับประกันผู้ส่งจ่าย”

มาตรา 940 บัญญัติว่า “ผู้รับอาวัลย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน”

มาตรา 967 บัญญัติว่า “ในเรื่องตัวแลกเงินนั้น บรรดาบุคคลผู้ส่งจ่ายก็ได้รับรองก็ดี สลากหลังก็ดี หรือรับประกันด้วยอาวัลก็ดี ย่อมต้องร่วมกันรับผิดชอบผู้ทรง”

ตามปัญหา การที่นำหรือออกตัวแลกเงินสั่งให้มานพจ่ายเงินให้สุชาดาโดยขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออกเป็นตัวระบุชื่อ การโอนทำโดยสลักหลังและส่งมอบตามมาตรา 917 การที่สุชาดาสลักหลังและส่งมอบตัวแลกเงินให้สุธี เป็นการโอนสิทธิในตัวให้สุธีโดยถูกต้องตามมาตรา 920 ต่อมาสุธีสลักหลังตัวฉบับนั้นให้สมหวัง เป็นการโอนตัวโดยชอบเช่นกัน สมหวังเป็นผู้ทรงตามมาตรา 904 ก่อนที่สุธีส่งมอบตัวให้สมหวัง สันทัดเพื่อนของสุธีมาลงลายมือชื่อหน้าตัวโดยไม่ได้เขียนข้อความใดเป็นการอาวัลตัวฉบับนี้ ตามมาตรา 938 วรรคสอง เมื่อไม่ได้เขียนว่าอาวัลใคร เป็นการอาวัลผู้ส่งจ่ายตามมาตรา 939 และรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ส่งจ่ายตามมาตรา 940

ส่วนมานพผู้จ่ายได้รับรองตัวฉบับนี้ก็ต้องผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นตามมาตรา 937

ดังนั้น ผู้รับผิดชอบตามตัวคือ นารีในฐานะผู้ส่งจ่ายตามมาตรา 914

สุชาดาและสุธีรับผิดชอบในฐานะผู้สลักหลังตามมาตรา 914

สันทัดอาวัลตัวโดยไม่ระบุว่าอาวัลใคร รับผิดชอบเช่นเดียวกันกับนารีผู้ส่งจ่าย มาตรา 938 วรรคสอง, 939, 940, 914

ส่วนมานพได้รับรองตัวต้องผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในตัวตามมาตรา 937

ผู้ส่งจ่าย ผู้สลักหลัง ผู้รับอาวัล ผู้รับรองตัวต้องร่วมรับผิดชอบในตัวร่วมกันตามมาตรา 967

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษาในเรื่องผู้รับผิดชอบตามตัวแลกเงินในฐานะลูกหนี้ตามตัวคือผู้ส่งจ่าย ผู้สลักหลัง ผู้รับรอง ผู้อาวัล ประเด็นที่ตรวจพบคือ

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบว่าลูกหนี้ในตัวฉบับนี้คือใคร จึงตอบสั้น ๆ ว่านารี รับผิดชอบในฐานะผู้ส่งจ่าย สุชาดาและสุธี รับผิดชอบในฐานะผู้สลักหลัง สันทัดรับผิดชอบในฐานะผู้อาวัล มานพรับผิดชอบในฐานะผู้รับรอง โดยไม่ได้ยกหลักกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ มาวินิจฉัย คือ ปพพ. มาตรา 914, 938 วรรค 2, 939, 940, 937 นักศึกษาจึงไม่ได้คะแนนตามที่ควรคือตกนั่นเอง

2. มีนักศึกษาจำนวนมากเข้าใจว่าสันทตลงลายมือชื่อด้านหน้าตัวเงินเป็นการรับรองตัวเงิน ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะผู้รับรองคือผู้จ่ายเท่านั้นที่จะรับรองตัวเงินได้ ดังนั้น มานพจึงเป็นผู้รับรองไม่ใช่สันทต ในส่วนของสันทต ต้องตอบมาตรา 938 วรรคสอง, 939, 940 ซึ่งเป็นผู้รับอาวัล
3. นักศึกษาจำนวนไม่น้อยตอบว่ามานพลงลายมือชื่อด้านหน้าตัวเงินเป็นการอาวัลตัวเงินในเรื่อง ความรับผิดชอบของมานพ ต้องตอบตามมาตรา 937 คือผู้จ่าย เมื่อรับรองแล้วย่อมผูกพันในอันจะจ่ายเงินจำนวนที่ รับรองตามเนื้อความแห่งคำรับรองของตน
4. นักศึกษาบางคนตอบว่าเมื่อมานพรับรองตัวเงินแล้ว ผู้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้สั่งจ่าย ผู้สลักหลัง ผู้อาวัล เป็นอันหลุดพ้นความรับผิด ซึ่งตามกฎหมายผู้ที่ลงลายมือชื่อในฐานะใดก็ต้องรับผิดชอบตามตัวเงินนั้น เพียงแต่หากผู้จ่ายรับรองตัวเงินผู้รับรองเป็นลูกหนี้ชั้นต้นที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ทรงตามมาตรา 937
5. มีนักศึกษากว่า 50% ตอบมาว่าผู้ลงลายมือชื่อในตัวเงินต้องรับผิดชอบโดยอ้างมาตรา 900 โดย ไม่ได้ยกหลักกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบในกรณีอื่น ๆ เลย ซึ่งตอบในลักษณะหว่านรวมไปหมด ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบเป็นใคร ๆ ไป จึงได้คะแนนน้อยมาก
6. มีนักศึกษาบางคนเข้าใจผิดว่าตัวฉบับนี้เป็นตัวผู้ถือ จึงวินิจฉัยผิดเป็นว่าโอนได้ โดยวิธีส่งมอบ ตามมาตรา 918 เมื่อมีการสลักหลังจึงเป็นการอาวัลผู้สั่งจ่ายตามมาตรา 921 ซึ่งตามโจทย์ก็ระบุชัดเจนว่าตัว ฉบับนี้ไม่ได้ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก จึงเป็นตัวระบุชื่อโอนโดยวิธีสลักหลังและส่งมอบตามมาตรา 917



กฎหมายพาณิชย์ ๔

รองศาสตราจารย์ ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี

คำถาม

นายเกิดลงทุน 50,000 บาท นายไก่อลงทุน 50,000 บาท นายกว้างลงทุน 40,000 บาท เข้าหุ้นส่วนทำอยู่ซ่อมรถยนต์ ลีนปีแรกห้างฯเป็นหนี้ค่าอะไหล่ยนต์ เป็นเงิน 50,000 บาท นายไก่อได้ลาออกจากห้างหุ้นส่วน ดังนั้นนายไก่อต้องรับผิดชอบหนี้ของห้างฯหรือไม่

นายเกิดและนายกว้างก็ยังคงดำเนินการอยู่ซ่อมรถยนต์ต่อมาพร้อมทั้งไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นายเกิดได้ซื้ออะไหล่จากบริษัทสมพรจำกัด และค้างชำระหนี้บริษัทสมพรจำกัด เป็นเงิน 20,000 บาท บริษัทสมพรจำกัด จึงฟ้องนายเกิดและนายกว้างให้รับผิดชอบหนี้ จงอธิบายว่า บุคคลทั้งสองต้องรับผิดชอบหนี้ของห้างหรือไม่ อย่างไร

เฉลย

ประเด็นแรก

ตามพพ.มาตรา 1051 บัญญัติว่า “ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วยังคงต้องรับผิดชอบหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนได้ออกจากห้างหุ้นส่วนไป”

ตามปัญหาในกรณีที่นายเกิด นายไก่อและนายกว้างได้เข้าหุ้นกันทำกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์ ถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่จำกัดจำนวน แม้หุ้นส่วนคนใดได้ออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วก็ยังคงต้องรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะออกจากห้างไป เมื่อนายไก่อได้ออกจากห้างไปโดยที่ห้างมีหนี้สินอยู่ 50,000 บาท นายไก่อยังคงต้องรับผิดชอบหนี้ของห้างนั้นอยู่ ไม่อาจปฏิเสธหนี้ดังกล่าวได้แต่อย่างใด

วิเคราะห์

ประเด็นแรกนี้ เป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะจับประเด็นและเข้าใจในเรื่องการที่หุ้นส่วนลาออกเป็นอย่างดี นั่นคือผู้เป็นหุ้นส่วนที่ลาออกนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนยังคงต้องรับผิดชอบ แต่ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นจะลาออก หากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกจากห้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

ประเด็นที่สอง

ตามปพพ.มาตรา 1070 บัญญัติว่า “เมื่อใดห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนผิदनัดชำระหนี้ เมื่อนั้นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนนั้นชอบที่จะเรียกให้ชำระหนี้เอาแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้”

ปพพ.มาตรา 1071 บัญญัติว่า “ในกรณีที่กล่าวมาในมาตรา 1070 นั้น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนนำพิสูจน์ได้ว่า

- (1) สินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนยังมีพอที่จะชำระหนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และ
- (2) การที่จะบังคับเอาแก่ห้างหุ้นส่วนนั้นไม่เป็นการยากจะหนี้ไซ้

ศาลจะบังคับให้เอาสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนนั้นชำระหนี้ก่อนก็ได้ สุดแต่ศาลจะเห็นสมควร”

ตามปัญหากรณีต่อมาคือนายเกิดและนายกว้างดำเนินกิจการต่อโดยนำห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนเมื่อเป็นห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน มีสภาพเป็นนิติบุคคล หนี้สินต่างๆจึงเป็นเรื่องที่นิติบุคคลนั้นต้องเข้าไปรับผิดชอบก่อน และลำดับต่อมาจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ยังคงต้องรับผิดชอบโดยไม่จำกัดจำนวนอยู่ เนื่องจากกเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญแม้จะจดทะเบียนก็ตาม ดังนั้นตามปพพ.มาตรา 1070 จึงกำหนดว่าหากห้างหุ้นส่วนผิदनัดชำระหนี้แล้วเท่านั้น เจ้าหนี้จึงสามารถมาเรียกชำระหนี้จากผู้เป็นหุ้นส่วนคือนายเกิดและนายกว้างได้ กรณีจากปัญหาจะเห็นได้ว่าการที่ห้างหุ้นส่วนไปซื้ออะไหล่จากบริษัทสมพรจำกัดมาแล้ว ค้างชำระหนี้อยู่อีก 20,000 บาท นั้นแสดงว่าห้างหุ้นส่วนได้ผิदनัดชำระหนี้แล้ว บริษัทสมพรจำกัดจึงสามารถฟ้องเรียกหนี้จากหุ้นส่วนทั้งสอง คือนายเกิดและนายกว้างได้ ทั้งนายเกิดและนายกว้างจะต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ตามปพพ.มาตรา 1071 ยังให้โอกาสต่อศาลที่อาจจะใช้ดุลยพินิจก่อนที่จะเรียกเอาหนี้จากนายเกิดและนายกว้าง หากปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนยังมีสินทรัพย์อื่นอยู่และไม่เป็นการยากที่จะบังคับเอามาชำระหนี้ก็ให้เรียกเอาสินทรัพย์จากห้างหุ้นส่วนได้ก่อนที่จะมาเรียกให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งสองเป็นผู้ชำระหนี้

ดังนั้นนายเกิดและนายกว้างไม่สามารถปฏิเสธการชำระหนี้ให้กับบริษัทสมพรจำกัดได้ เพราะเป็นหนี้ที่ห้างหุ้นส่วนผิदनัดชำระหนี้แล้ว เพียงแต่ศาลอาจจะบังคับเอากับสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้นหากยังมีอยู่และไม่เป็นการยาก แต่หากไม่พอนายเกิดและนายกว้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวอยู่นอยู่ดี

วิเคราะห์

ประเด็นที่สองนี้เป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน สิ่งที่พบข้อผิดพลาดในการตอบประเด็นนี้คือ

๑. ประเด็นของการเป็นห้างจดทะเบียนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ที่เจ้าหนี้จะต้องเรียกหรือฟ้องเอากับห้างที่เป็นนิติบุคคลก่อน ยังไม่สามารถมาเรียกเอากับผู้เป็นหุ้นส่วนได้ จะเรียกเอากับผู้เป็นหุ้นส่วนได้ก็ต่อเมื่อห้างที่เป็นนิติบุคคลนั้นผิदनัดชำระหนี้ ตามปัญหาโจทย์บอกชัดเจนว่าห้างนิติบุคคลค้างชำระหนี้กับเจ้าหนี้ นั่นก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนผิदनัดชำระหนี้ เมื่อผิदनัดชำระหนี้จึงมาเรียกจากผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตามปพพ.มาตรา ๑๐๗๐ ส่วนใหญ่นักศึกษาจะจำหลักกฎหมายในประเด็นที่ว่า “ผิदनัดชำระหนี้” ไม่ชัดเจน เวลานำมา

วิเคราะห์หนี้ที่ค้างชำระจึงเหมือนกับมองข้ามประเด็นนี้ไป นักศึกษาจะให้ความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นธรรมชาติการค้า ของห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา ๑๐๕๐ ซึ่งใช้มาตรานี้ไม่ได้เพราะห้างหุ้นส่วนนี้จดทะเบียนแล้ว เมื่อจดทะเบียนก็ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ เมื่อทำตามวัตถุประสงค์ก็ผูกพันห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงต้องฟ้องห้างหุ้นส่วนก่อนถ้าไม่ชำระแล้วจึงมาฟ้องผู้เป็นหุ้นส่วนได้

๒. เมื่อบริษัทเจ้าหนี้มาเรียกชำระหนี้จากผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นนายเกิดและนายกว้างซึ่งเป็นหุ้นส่วนสามัญที่ต้องรับผิดชอบโดยไม่จำกัดโดยต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะที่เป็นลูกหนี้ร่วม ดังนั้นบริษัทสมพรจำกัดจะฟ้องคนเดียวคนหนึ่งหรือทั้งสองคนก็ได้ ทั้งนายเกิดและนายกว้างไม่อาจปฏิเสธการชำระหนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนี้ค้างชำระอยู่ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากมีข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้นยังมีทรัพย์สินของห้างอยู่ที่จะพอชำระหนี้ได้และไม่เป็นการยากที่จะบังคับเอาได้ ศาลอาจยังไม่เรียกเอาจากนายเกิดและนายกว้างก็ได้สุดแต่ศาลจะเห็นสมควร ตามหลักกฎหมายแพ่ง มาตรา ๑๐๗๑ ข้อนี้ถ้านักศึกษาที่จำมาตรา ๑๐๗๐ ได้ก็มักจะจำมาตรานี้ได้ด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะจำโดยจำว่าเป็นสิทธิขายเบี่ยง ซึ่งจะเรียกสิทธิขายเบี่ยงหรือสิทธิใดก็สุดแล้วแต่เพียงแต่ถ้ายังมีทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนมีอยู่และไม่เป็นการยากที่จะเรียกชำระหนี้ได้ ศาลก็จะไปเรียกเอาจากส่วนนั้นก่อนได้ สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจึงคล้ายกับว่าได้รับการปกป้องจากนิติบุคคลอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนั่นเอง

ดังนั้นที่สำคัญคือ การวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าเป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบใด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนหรือไม่ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อที่จะได้นำหลักกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป และมาตราที่สำคัญพยายามจำตัวบทให้ได้ เวลาจะนำมาใช้จะได้แม่นยำ ได้ตัวบทแล้ว ก็พอที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์ พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

ข้อ 1

พนักงานอัยการฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงที่มีนายหนึ่งเป็นหัวหน้าศาล นายสองเป็นผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาล และนายสามเป็นผู้พิพากษา ฟ้องโจทก์ขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูง จำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายหนึ่งจ่ายสำนวนดังกล่าวให้นายสามเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา เมื่อคดีเสร็จการพิจารณา แต่ก่อนทำคำพิพากษา นายสามได้ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น ส่วนนายหนึ่งก็ลาป่วย นายสองตรวจสำนวนแล้วลงลายมือชื่อทำคำพิพากษา โดยจำคุกจำเลยหกเดือน บวกโทษจำคุกอีกหกเดือนในคดีก่อนที่รอการลงโทษไว้ เป็นจำคุกสิบสองเดือน

ให้วินิจฉัยว่า การทำคำพิพากษานายสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

แนวตอบ

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 9 วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงว่างลง หรือเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทน...”

มาตรา 25 บัญญัติว่า “ในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาคณะเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้น ดังต่อไปนี้

...

(5) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จะลงโทษจำคุกเกินหกเดือน หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท...ไม่ได้”

มาตรา 29 บัญญัติว่า “ในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้ ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษา...ทั้งนี้ หลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้ว

...

(3) ในศาลชั้นต้น ได้แก่ ...ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล...

ให้ผู้ทำการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 13 มีอำนาจตาม...(3) ด้วย"

มาตรา 30 บัญญัติว่า "เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 หมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั้นพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่... หรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้"

วินิจฉัย

การที่นายสามผู้พิพากษาศาลแขวงซึ่งเป็นองค์คณะพิจารณาคดีเสร็จแล้ว ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นในระหว่างการทำคำพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 30 นายหนึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้ทำการแทนจึงมีอำนาจตรวจสอบและทำคำพิพากษาได้ ตามมาตรา 29 (3) หรือมาตรา 29 วรรคท้ายแล้วแต่กรณี เมื่อปรากฏว่านายหนึ่งลาป่วย นายหนึ่งจึงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นายสองที่มีอาวุโสในศาลจึงเป็นผู้ทำการแทน ตามมาตรา 9 วรรคสอง มีอำนาจตรวจสอบและทำคำพิพากษาได้ และที่นายสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยหกเดือนก็ไม่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 25 (5) ส่วนการบอกโทษจำคุกอีกหกเดือนในคดีก่อนที่รอการลงโทษไว้นั้น เป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 นายสองก็มีอำนาจทำได้ ดังนั้น การทำคำพิพากษาของนายสองจึงชอบด้วยกฎหมาย

วิเคราะห์

คำถามในข้อนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องนำมาวินิจฉัย ดังนี้

1. ประเด็นกรณีมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เกิดขึ้นในระหว่างการทำคำพิพากษา ซึ่งจำต้องเอามาตรา 29 วรรคหนึ่ง และ 30 มาปรับใช้
2. ประเด็นในการมีอำนาจตรวจสอบและทำคำพิพากษา ตามมาตรา 29 ของหัวหน้าศาลหรือผู้ทำการแทนแล้วแต่กรณี
3. ประเด็นผู้ทำการแทนหัวหน้าศาลตามมาตรา 9
4. ประเด็นการลงโทษจำคุกจำเลย ตามมาตรา 25(5) ประกอบกับการบอกโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด สำหรับข้อสอบข้อนี้คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบหลักกฎหมายไม่ครบถ้วน ตามหลักกฎหมายที่ต้องนำมาใช้พิจารณา นักศึกษาส่วนใหญ่จำหลักกฎหมายได้เพียงแค่สองมาตราเท่านั้น อีกสองมาตราจำไม่ได้เลยไม่ได้เขียนมา ทำให้คะแนนในส่วนหลักกฎหมายนี้ได้น้อยลงไปกว่าที่ควรจะได้

สำหรับนักศึกษาบางท่านเขียนรวมหลักกฎหมายทั้งสี่มาตราในหลักกฎหมายเดียวกันเลย ซึ่งถ้าหากจะพิจารณาว่าหลักกฎหมายดังกล่าวเขียนไม่ถูกต้องก็ย่อมได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก ดังนั้น แม้จะเขียนรวมหลักกฎหมายกันมา เชื่อแน่ว่านักศึกษาก็ย่อมได้คะแนนในส่วนหลักกฎหมายนี้ไปอย่างแน่นอน

2. ข้อผิดพลาดประการที่สองคือ นักศึกษาจำมาตรา 25 (5) ไม่ได้ (“พิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จะลงโทษจำคุกเกินหกเดือน หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท...ไม่ได้”) ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยสำหรับนักศึกษาที่จำตัวบทไม่ได้ โดยเฉพาะในส่วนการลงโทษ จะตอบข้อสอบอย่างมั่นใจ เนื่องจากจะนำการลงโทษในการพิจารณาของศาลมาตอบ คือ อัตราโทษอย่างสูงที่กำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท ดังนั้นการลงโทษของศาลจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องนำมาพิจารณา แต่สำหรับนักศึกษาที่จำหลักกฎหมายได้แบบไม่แน่ชัด ก็จะทำให้เกิดความไม่แน่ใจ และตอบผิดไปในที่สุด ทำให้คะแนนส่วนนี้ถูกตัดไป

3. ข้อผิดพลาดประการสุดท้ายคือการที่นักศึกษาไม่ได้อ่านพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาสอบ ทำให้ต้องแตงนินทา หรือสร้างกฎหมายประกอบกับการสร้างหลักความน่าจะเป็นขึ้นมาโดยตนเอง หรืออาจกล่าวได้ว่าสร้างกฎหมายเองใช้เอง ทำตัวเสมือนเป็นรัฐาธิปัตย์ การแต่งกฎหมายโดยตนเองนั้น แน่ช้อย่อมไม่ได้คะแนนจากผู้ตรวจ เนื่องจากไม่มีหลักใดๆตามตัวบทกฎหมายเลย มีแต่หลักความน่าจะเป็น น่าจะถูกตัด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาท่านใดที่แต่งกฎหมายขึ้นมาเอง ก็น่าจะสอบไม่ผ่านอย่างแน่นอน

ข้อ 3

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้ารับการศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้าจากจำเลย แล้วเกิดอาการผิดปกติเป็นแผลเน่าอักเสบจนต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาบำบัดในโรงพยาบาลของรัฐหลายครั้งจึงกลายเป็นปกติ จำเลยทำศัลยกรรมใบหน้าให้แก่โจทก์โดยปราศจากความระมัดระวัง และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาลที่โจทก์ได้จ่ายไปเป็นเงิน 10,000 บาท จำเลยให้การว่าจำเลยทำศัลยกรรมใบหน้าให้โจทก์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จำเลยไม่ได้ประมาท จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ในการพิจารณาคดีโจทก์นำพยานเข้าสืบได้ความแต่เพียงว่า ได้ให้จำเลยทำศัลยกรรมใบหน้า แต่ผลออกมาแทนที่จะสวยกลับแย่กว่าเดิมจนกระทั่งต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐหลายครั้ง ส่วนจำเลยไม่สืบพยาน

ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะพิพากษาให้ใครเป็นฝ่ายแพ้คดี

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น แต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมาย

หรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว

วินิจฉัย

การรักษาพยาบาลถูกต้องตามหลักวิชาการในทางการแพทย์ เป็นข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์ โจทก์จึงได้รับประโยชน์จากข้อเท็จจริงนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ดังนั้น โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์เฉพาะเงื่อนไขที่จะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนี้ เมื่อโจทก์นำสืบได้ว่า โจทก์ได้ให้จำเลยทำศัลยกรรมใบหน้าโจทก์ ถือว่าโจทก์ได้นำสืบเงื่อนไขที่จะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานแล้ว ต่อไปจึงเป็นภาระการพิสูจน์ของจำเลยที่จะต้องนำสืบว่า จำเลยได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานการแพทย์อย่างไร เมื่อจำเลยไม่สืบแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงดังกล่าว ต้องฟังว่าจำเลยกระทำโดยประมาท

ดังนั้น ศาลต้องพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายแพ้คดี

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบกึ่งยากกึ่งง่าย หมายความว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อสอบข้อนี้ได้ถูกต้อง โดยอาศัยหลักเหตุผลง่ายๆที่ว่า หากไม่นำสืบก็แพ้คดี เมื่อจำเลยไม่นำสืบก็ต้องแพ้คดี ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่ความยากอยู่ตรงที่ว่า นักศึกษาจะหาหลักกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้เจอหรือไม่ มีนักศึกษาจำนวนน้อยที่สามารถปรับกรณีดังกล่าวเข้ากับหลักกฎหมายตามมาตรา 84/1 ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาส่วนมากจะอ้างเพียงแค่ ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นย่อมต้องนำสืบ เมื่อจำเลยไม่นำสืบ จึงต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

ข้อผิดพลาดสำหรับนักศึกษาในข้อนี้ ก็คือ การไม่สามารถปรับโจทย์เข้ากับหลักกฎหมาย มาตรา 84/1 ได้ เนื่องจากอาจจะลืม หรือยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อไม่อ้าง มาตรา 84/1 มา คະแนนในส่วนหลักกฎหมายก็จะหายไป ต่อมาในส่วนวินิจฉัย หากไม่มีการอ้าง มาตรา 84/1 จะทำการวินิจฉัยถูกต้องอย่างไร และสุดท้ายที่นักศึกษาหลายท่านได้คะแนนในส่วนนี้ไปคือ การพินิจ หรือสรุปประเด็นว่าจำเลยผิด แต่อย่างไรก็ดี แม้จะคำตอบจะถูก แต่หลักกฎหมายไม่มีและวินิจฉัยไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถทำให้นักศึกษาสอบผ่านได้นะครับ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

คำถาม

ในคดีแพ่งเรื่องหนึ่ง จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์ได้ยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดเวลาเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดแล้ว แต่ศาลกลับมีคำสั่งให้โจทก์นำพยานมาสืบต่อศาลอีกในวันนัดสืบพยานโจทก์ไม่มาศาลและไม่นำส่งเอกสารแทนการสืบพยาน ถามว่า

- ก. ศาลมีอำนาจกำหนดให้โจทก์ต้องนำพยานมาสืบต่อศาลอีกหรือไม่
- ข. เมื่อโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานและไม่นำส่งเอกสารแทนการสืบพยาน เช่นนี้ศาลจะต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างใดต่อไป

ข้อวิจารณ์

ข้อสอบข้อนี้นักศึกษาอาจคิดว่ายาก เพราะมีคำถามถึง 2 ข้อ โดยเฉพาะข้อ ข. ที่ถามว่าศาลจะต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างใดต่อไป ความจริงแล้วข้อสอบข้อนี้ถือว่าไม่ยากนักเพราะเป็นการถาม-ตอบตามตัวบทตรง ๆ และได้กล่าวไว้แล้วในคำบรรยาย เพียงแต่นักศึกษาอ่านคำบรรยายให้ละเอียดก็จะสามารถตอบได้ถูกต้อง ส่วนคำถามที่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งอย่างใดนั้น เป็นคำถามที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในข้อสอบแทบทุกสถาบัน แท้จริงแล้วก็มีความหมายเพียงว่าถ้าโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานและไม่นำส่งเอกสารแทนการสืบพยานเช่นนี้ จะเกิดผลประการใดกับโจทก์เท่านั้น

ตอบคำถามข้อ ก. ศาลมีอำนาจกำหนดให้โจทก์ต้องนำพยานมาสืบต่อศาลอีกหรือไม่

เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 198 วรรคแรกบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องยื่นคำขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด หากโจทก์ไม่ยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ ฉะนั้นตามอุททาหรณ์ เมื่อโจทก์ได้ยื่นคำขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดแล้ว ก็มีผลเพียงว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามที่มาตรา 198 บัญญัติไว้แล้วเท่านั้น มิได้หมายความว่าศาลจะต้องพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยไม่ต้องสืบพยานแต่อย่างใด เพราะมาตรา 198 ทวิ วรรคสอง ยังให้อำนาจศาลที่จะมีคำสั่งให้สืบพยานเกี่ยวกับข้ออ้างของโจทก์หรือพยานหลักฐานอื่นไปฝ่ายเดียวตามที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

หมายความว่าศาลอาจให้สืบพยานก็ได้ ไม่ให้สืบโดยสั่งงดเสียก็ได้แล้วแต่ศาลเห็นว่าจำเป็นต้องสืบพยานหรือไม่ แต่เมื่อศาลสั่งให้สืบพยานแล้วก็ต้องแจ้งวันนัดให้คู่ความทราบต่อไป (คำบรรยายหน้า 4-24) ยกเว้นแต่ในคดีเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ คดีทั้งสามประเภทนี้กฎหมายกำหนดให้ศาลต้องสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว จะให้งดการสืบพยานและพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเลยทันทีไม่ได้ ในการนี้ศาลยังมีอำนาจที่จะเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

ตอบคำถามข้อ ข. เมื่อโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานและไม่นำส่งเอกสารแทนการสืบพยาน เช่นนี้ศาลจะต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างไรต่อไป

เมื่อโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานและไม่นำส่งเอกสารแทนการสืบพยาน เช่นนี้มาตรา 198 ทวิวรรคห้าบัญญัติว่าถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูล และให้ศาลพิพากษายกฟ้องของโจทก์ ฉะนั้นในคดีนี้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์เท่านั้น (คำบรรยายหน้า 4-26) ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีโจทก์โดยถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 202 ไม่ได้ เพราะเป็นกรณีตามที่มาตรา 198 ทวิบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว

ฉะนั้น ศาลต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์เท่านั้น

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และเคยออกข้อสอบมาหลายครั้งติดต่อกันแล้ว การพิจารณาโดยขาดนัดแบ่งออกได้เป็น การขาดนัดยื่นคำให้การ (ตั้งแต่มาตรา 197 ถึงมาตรา 199 จ) และการขาดนัดพิจารณา (ตั้งแต่มาตรา 200 ถึงมาตรา 207) ซึ่งมีส่วนที่ทั้งคล้ายกันและต่างกัน ฉะนั้นในการอ่านเพื่อศึกษานั้น ขอย้ำว่านักศึกษาต้องอ่านทั้งสองกรณีควบคู่กันไปเสมอ และพิจารณาเปรียบเทียบทั้งข้อที่เหมือนกันและแตกต่างกันให้เข้าใจ โดยเฉพาะกรณีการร้องขอพิจารณาคดีใหม่ซึ่งถือว่ายากที่สุดในเรื่องนี้

เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องพิจารณาโดยขาดนัด ขอให้นักศึกษาย้อนไปอ่านวิจารณ์ข้อสอบไล่ภาค 1/2554 ประกอบด้วย เพราะได้ยกตัวอย่างที่พลิกแพลงและไม่ได้กล่าวถึงไว้ในคำบรรยายที่น่าสนใจหลายประการ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

อาจารย์ เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

นายโต นายเร และนายมี ร่วมกันปล้นรถยนต์ของนายเสือที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปขายให้นายแหวนที่จังหวัดลำปาง ต่อมาตำรวจจับกุมตัวทั้งสี่คนได้ พนักงานอัยการจึงฟ้องนายโต นายเร นายมี และนายแหวน ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้ลงโทษนายโต นายเร และนายมี ในความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และขอให้ลงโทษนายแหวนในความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี นายโต นายเร และนายมี ให้การรับสารภาพ ส่วนนายแหวนอ้างว่าการซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลจังหวัดลำปาง ดังนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่มีอำนาจพิจารณาความผิดฐานรับของโจร

ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของนายแหวนรับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ มาตรา 24 เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เป็นต้นว่า

- (1) ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำการโดยผู้กระทำผิดคนเดียวกัน หรือผู้กระทำผิดหลายคน เกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเป็นตัวการ ผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตาม
- (2) ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำการโดยมีเจตนาอย่างเดียวกัน หรือโดยผู้กระทำผิดทั้งหลาย ได้คบคิดกันมาแต่ก่อนแล้ว
- (3) ปรากฏว่าความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้นโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทำผิดอื่นให้พ้นจากรับโทษในความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทำได้

ดังนั้นจะฟ้องคดีทุกเรื่อง หรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้

ถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกัน ศาลซึ่งมีอำนาจชำระ ก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไว้ก่อน

จากบทกฎหมายดังกล่าว การกระทำความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยความรวดเร็วและเกิดผลดีทางด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ถ้าเป็นคดีความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันซึ่งมีอัตราโทษไม่เท่ากัน โจทก์จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้

จากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายโต นายเร และนายมี ร่วมกันกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนนายแหวนกระทำความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี ที่จังหวัดลำปาง แม้ความผิดฐานปล้นทรัพย์กับความผิดฐานรับของโจรเกิดขึ้นต่างท้องที่กัน คือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง แต่ทรัพย์ที่ถูกปล้นกับรับของโจรนั้นเป็นทรัพย์สิ่งเดียวกัน คือ รถของนายเลื้อ ผู้เสียหาย โดยถูกปล้นไปจากท้องที่หนึ่งแล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้รับของโจรในอีกท้องที่หนึ่ง จึงเป็นความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกัน โดยมีผู้กระทำความผิดหลายคน มีทั้งที่เป็นตัวการในความผิดฐานปล้นทรัพย์ อันได้แก่นายโต นายเร และนายมี และผู้กระทำความผิดฐานรับของโจร ได้แก่ นายแหวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 (1) และเมื่อเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษไม่เท่ากัน พนักงานอัยการจึงฟ้องนายโต นายเร นายมี และนายแหวน ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีอำนาจชำระคดีในความผิดฐานปล้นทรัพย์ซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานรับของโจรก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 วรรคสอง

ดังนั้น พนักงานอัยการจึงฟ้องนายแหวนในความผิดฐานรับของโจรต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานปล้นทรัพย์ได้ เพราะความผิดฐานปล้นทรัพย์มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานรับของโจร การที่นายแหวนอ้างว่าศาลจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีอำนาจพิจารณาความผิดฐานรับของโจรจึงรับฟังไม่ได้

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจพิจารณาความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจพิจารณาความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ นักศึกษาควรยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถาม กล่าวคือ ถ้าความผิดหลายฐานได้กระทำความผิดโดยผู้กระทำผิดคนเดียวกัน หรือผู้กระทำผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานจะเป็นตัวการ ผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตาม โจทก์สามารถฟ้องคดีทุกเรื่อง หรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 (1) และมาตรา 24 วรรคสอง

ประการที่สอง ประเด็นคำถามในเรื่องนี้มีประเด็นย่อยที่ต้องอธิบายและวินิจฉัยอยู่ 2 ประเด็น กล่าวคือ ความผิดฐานปล้นทรัพย์กับความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกัน โดยมีผู้กระทำ

ความผิดหลายคน ประการต่อมาเมื่อเป็นความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกัน โจทก์จึงฟ้องตัวการในความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ อันได้แก่นายโด นายเร และนายมี และผู้กระทำความผิดฐานรับของโจร ได้แก่ นายแหวน ต่อศาล จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีอำนาจชำระคดีในความผิดฐานปล้นทรัพย์ซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานรับของโจรก็ได้

ประการที่สาม นักศึกษาหลายคนสามารถตอบคำถามได้ว่าสามารถฟ้องนายแหวนในความผิดฐาน รับของโจรที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ เพราะ ความผิดฐานปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มีโทษสูงกว่า ความผิดฐานรับของโจร แต่นักศึกษาไม่ได้อธิบายว่า ความผิดทั้งสองฐานนี้เป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน จึงเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ประการที่สี่ มีนักศึกษาบางส่วนตอบว่า โจทก์ไม่สามารถฟ้องนายแหวนในความผิดฐานรับของโจร ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ เพราะ เป็นคนละคดีกัน หรือ นายแหวนไม่ใช่ตัวการในความผิดฐานปล้นทรัพย์ หรือ นายแหวนได้กระทำความผิดในจังหวัดลำปาง อันเป็นการแสดงให้เห็นว่านักศึกษาไม่ทราบถึงหลักกฎหมายดังกล่าว จึงไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษา ในเรื่อง เขตอำนาจศาล อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องเขตอำนาจศาล ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมทำเรื่อง และแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือ วันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถาม ปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์ วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

นายประยูรซื้อที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งจากนายนฤตลซึ่งแบ่งขายที่ดินให้แก่นายประยูร โดยนายนฤตลดกลงกับนายประยูรให้มีทางผ่านที่ดินของนายนฤตลไปยังวัดได้โดยให้เป็นทางภาระจำยอม แต่ไม่ได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ นายประยูรได้ใช้ทางนั้นโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นนายนฤตลได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินนั้นให้แก่นางนวลปราง โดยนางนวลปรางไม่ทราบมาก่อนว่านายประยูรได้ใช้ทางนั้นอย่างทางภาระจำยอม และนางนวลปรางประสงค์จะปิดทางเข้าออกดังกล่าวโดยอ้างว่านายประยูรไม่มีสิทธิต่อสู้นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้

ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของนางนวลปรางถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่

ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมีได้จดทะเบียนไว้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว”

ตามปัญหานายประยูรซื้อที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งจากนายนฤตลซึ่งแบ่งขายที่ดินให้แก่นายประยูร โดยนายนฤตลดกลงกับนายประยูรให้มีทางผ่านที่ดินของนายนฤตลไปยังวัดได้โดยให้เป็นทางภาระจำยอม แต่ไม่ได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่นนี้ เป็นการได้ภาระจำยอมโดยนิติกรรมอันเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เมื่อนายประยูรยังไม่จดทะเบียนการได้มาจึงไม่บริบูรณ์ ตามป.พ.พ.มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่านายประยูรได้ใช้ทางนั้นโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ก็ไม่อาจเป็นการได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความครอบครองปรปักษ์ อันจะเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ตามป.พ.พ.มาตรา 1299 วรรคสอง เพราะนายประยูรใช้ทางนั้นโดยอาศัยสิทธิของนายนฤตล

เมื่อไม่ปรากฏว่านายประยูรได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการใช้ทางนั้นโดยบอกกล่าวไปยังนายนฤดล ว่าไม่เจตนาจะใช้ทางนั้นโดยอาศัยสิทธิของนายนฤดล อีกต่อไป ดังนั้น เมื่อนายนฤดลจดทะเบียนโอนขายที่ดินนั้นให้แก่ นางนวลปราง นางนวลปรางซึ่งเป็นบุคคลภายนอกย่อมมีสิทธิในที่ดินแปลงนั้น นายประยูรไม่อาจยกสิทธิในการจะจำยอมดังกล่าวขึ้นต่อสู้นางนวลปรางได้แต่อย่างใด นางนวลปรางย่อมมีสิทธิปิดทางเข้าออกดังกล่าวโดยอ้างว่านายประยูรไม่มีสิทธิต่อสู้ตนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้

สรุป ข้ออ้างของนางนวลปรางถูกต้อง

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้ นักศึกษามักจะหลงไปตอบว่าเป็นการได้ภาระจำยอมมาโดยอายุความ โดยอาศัยอายุความครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1401 ประกอบมาตรา 1382 ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการได้ทรัพย์สินมาโดยการมีนิติสัมพันธ์ต่อกันนั้น ผู้ได้มาจะอ้างอายุความครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 ได้ จะต้องบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1381 เสียก่อน หากมิได้บอกกล่าวเช่นนั้นจะครอบครองเป็นเวลานานเท่าใดก็หาอาจอ้างอายุความครอบครองปรปักษ์ได้ไม่ ในกรณีนี้จึงไม่อาจอ้างภาระจำยอมโดยอายุความได้

การได้ภาระจำยอมมาโดยนิติกรรม เมื่อมิได้ทำมาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมไม่บริบูรณ์ นั่นคือยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้รับโอนไม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์ว่าบุคคลภายนอกนั้นจะเสียค่าตอบแทนหรือสุจริตหรือไม่



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล

คำถาม

จงวิเคราะห์พัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน เกี่ยวกับที่มาและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในประชาคมโลก กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

แนวตอบ

พัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับที่มาและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในประชาคมโลก กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นผลมาจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ และพลวัตรของกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านบ่อเกิดและที่มาของกฎหมายได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งมีบ่อเกิดที่มาจากพัฒนาการของจารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งต้องอาศัยวิวัฒนาการที่ยาวนานจนค่อยๆเป็นที่ยอมรับโดยมีองค์ประกอบทางด้านเวลา สารัตถะและความเชื่อว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาช้านานเป็นกฎหมาย มาสู่วิวัฒนาการการเจรจาทำสนธิสัญญาโดยอาศัยเจตจำนงของรัฐซึ่งมีความรวดเร็ว และกระทำได้ทันที ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ดังเห็นได้จากประเภทของบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนี้

บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศมีหลายประการ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือสนธิสัญญา และที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แก่ จารีตประเพณีระหว่างประเทศและ หลักกฎหมายทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีบ่อเกิดซึ่ง มาตรา 38 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศบัญญัติว่าเป็นบ่อเกิดลำดับรอง กล่าวคือ แนวคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

การกระทำฝ่ายเดียวเป็นอีกบ่อเกิดหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นบ่อเกิดที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในมาตรา 38 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

สำหรับบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศจะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ องค์ประกอบทางด้านเวลาซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติของรัฐในกฎหมายใดๆ มาเป็นเวลาช้านาน จนตกผลึกเป็นกฎหมาย โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญด้วยคือ องค์ประกอบทางด้านวัตถุประสงค์ว่าเป็นที่เห็นประจักษ์ว่ามีการปฏิบัติของรัฐมาช้านานในจารีตประเพณีนั้นๆ และ การที่รัฐปฏิบัติเยี่ยงนั้นมาช้านาน เพราะมีความเชื่อว่าสิ่งที่รัฐปฏิบัตินั้นเป็นกฎหมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากว่าจารีตประเพณีระหว่างประเทศจะได้รับ

การวิวัฒนาการเป็นกฎหมายระหว่างประเทศต้องอาศัยเวลาอย่างช้านาน และบ่อเกิดของกฎหมายที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไปก็ต้องมีความถูกต้อง แน่หน่ว่าหลักเกณฑ์นั้นๆเป็นหลักกฎหมายทั่วไป รัฐทั้งหลายเห็นในความเป็นหลักกฎหมายตามความถูกต้อง ผิดชอบชั่วดี อันเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นบ่อเกิดของกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสองประเภทอาศัยการก่อตัวที่ยาวนาน และมั่นคง

ส่วนบ่อเกิดของกฎหมายที่เป็นสนธิสัญญาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการแสดงเจตนาของรัฐที่จะผูกพันกันตามเจตจำนงที่แสดงออก และจะปฏิบัติตามเป็นบ่อเกิดของกฎหมายที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามบริบทของสังคมและประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในยุคใหม่มีพลวัตสูง อาจเกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐในการแสดงเจตนาที่จะผูกพันระหว่างกันสร้างเขตเศรษฐกิจการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เปิดเสรีทางการค้า จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ หรือเขตการค้าเสรี ด้วยการลงนามทำสนธิสัญญาต่อกัน และผูกพันปฏิบัติตามผลของสนธิสัญญาดังกล่าวได้ นับได้ว่า บ่อเกิดของกฎหมายที่เป็นสนธิสัญญาได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบันต่อการเกิดขึ้น วิวัฒนาการ และ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับบ่อเกิดและการบังคับใช้กฎหมายจึงมุ่งเน้นที่การจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และ ระดับภูมิภาค เป็นส่วนสำคัญมากขึ้น เพราะใช้ระยะเวลาอันสั้น จัดทำได้ทันที และไม่ต้องรอรระยะเวลาในการตกลงของกฎหมาย มีความสะดวก และ เปลี่ยนแปลงได้ ยกเลิกได้ ตามเหตุ ปัจจัย ความจำเป็น ตามความประสงค์ และตามบริบทของสังคม

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบ่อเกิดของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ และพลวัตทางด้านเศรษฐกิจ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการก่อเกิดกฎหมายในรูปสนธิสัญญา กับความต้องการของสังคมทางด้านเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นการกำหนดกรอบทางกฎหมายของสังคมปัจจุบันบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง และ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับบทบาทของเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม

นักศึกษาที่ไม่สามารถตอบข้อสอบข้อนี้ได้เนื่องจากไม่เข้าใจกระบวนการก่อเกิดกฎหมายในรูปสนธิสัญญา และ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ การจะสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้ นักศึกษาจะต้องศึกษาจากเอกสารการสอน และรับฟังข่าวสาร ข้อมูล ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ หมั่นวิเคราะห์ พลวัตทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในระดับระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอและมีความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวด้วย

คำถาม

จงอธิบายหลักกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และ ขั้นตอนกระบวนการในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยละเอียด

แนวตอบ

หลักกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และ ขั้นตอนกระบวนการในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศมีดังต่อไปนี้

การทำสนธิสัญญานั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลักการแห่งอำนาจอธิปไตยกับความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดอำนาจอธิปไตยบางส่วนของรัฐ เพื่อผูกพันรัฐตามสนธิสัญญา หลักการพื้นฐานที่สำคัญในการทำสนธิสัญญา ได้แก่ หลักการกระทำโดยสุจริต (Good Faith หรือ Bona fide) หลักการแสดงเจตนา หรือการแสดงเจตจำนงโดยอิสระ หรือการแสดงเจตนาโดยสมัครใจ (Free Consent) ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำสนธิสัญญา และ หลักการที่เป็นที่ยอมรับในทางระหว่างประเทศ เช่นหลัก *pacta sunt servanda*

รัฐทุกรัฐในประชาคมระหว่างประเทศมีอำนาจอธิปไตยที่เท่าเทียมกันไม่ว่ารัฐเล็ก หรือรัฐใหญ่ การทำสนธิสัญญาจึงควรอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักการเช่นว่านี้ โดยที่รัฐทุกรัฐมีอำนาจในการทำสนธิสัญญา อำนาจในการทำสนธิสัญญาของรัฐ จะกระทำผ่านตัวแทนของรัฐ ซึ่งตัวแทนของรัฐในการทำสนธิสัญญาโดยตำแหน่ง หรือ โดยมีอำนาจหน้าที่ (Ex Officio) ได้แก่

(ก) ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีความในการดำเนินการใดๆ หรือการกระทำทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา

(ข) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต มีอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ หรือการรับเอา ข้อบทของสนธิสัญญาที่กระทำระหว่างรัฐผู้รับกับรัฐผู้ส่งทูตนั้น ซึ่งกรณีนี้ใช้สำหรับการทำสนธิสัญญาสองฝ่ายระหว่างสองรัฐนั้นเท่านั้น

(ค) ผู้เป็นตัวแทนรัฐ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรใดขององค์การระหว่างประเทศ โดยมีอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับข้อบทของสนธิสัญญาในการประชุมระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรขององค์การระหว่างประเทศนั้นๆ โดยผู้แทนเหล่านั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ (accredited) ผู้แทนรัฐเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็ม Full Powers (Art. 47 of Vienna Convention on the law of treaties 1969)

นอกจากนี้รัฐอาจจะแต่งตั้ง มอบอำนาจให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลเป็นตัวแทนรัฐผู้มีอำนาจเต็ม ในการเจรจา ทำสนธิสัญญาได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจเต็ม "Full Powers" ในการเจรจา (negotiation) ยอมรับ (Acceptance) รับรอง (Adoption) ข้อบทของสนธิสัญญา และในการแสดงเจตนาของรัฐในการที่รัฐจะผูกพันตามผลของสนธิสัญญา หรือเพื่อที่จะกระทำการใดๆ ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา

รัฐภาคีไม่อาจปฏิเสธความผูกพันต่อสนธิสัญญาที่ตัวแทนได้กระทำแล้ว กล่าวคือ รัฐไม่อาจจะกล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ในการแต่งตั้งผู้แทนของรัฐนั้นซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐนั้นๆ มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ผูกพันตามผลของสนธิสัญญาที่กระทำขึ้นโดยการแสดงเจตนาของรัฐบาลโดยผู้แทนบุคคลนั้น เว้นแต่ความไม่สมบูรณ์เพราะการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภายในนั้นเป็นที่ทราบอย่างประจักษ์แจ้ง และการแต่งตั้งที่ไม่ชอบนั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายภายในที่สำคัญอย่างยิ่งด้วย จึงเป็นสิ่งที่ไทยพึงระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำสนธิสัญญา

หลังจากที่รัฐภาคีได้เจรจา (Negotiation) ตกลง และยกร่าง (Draft) สนธิสัญญา ตลอดจนพิจารณา ร่างสนธิสัญญา จนได้ข้อบทของสนธิสัญญาตามที่รัฐภาคีเห็นชอบแล้ว ภาคีทั้งหลายก็จะให้การรับรองร่างสนธิสัญญา (Adoption) ที่เรียกว่าเป็นการรับรองชั่วคราว และให้ความเห็นชอบรับรองความถูกต้องแท้จริงของข้อบทของสนธิสัญญา (Authentication) ตามที่ได้ตกลงกันนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการที่รัฐภาคีพร้อมที่จะแสดงความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญา (Expressing consent to be bound by the treaty) อันเป็นการรับรองขั้นสุดท้าย ซึ่งการให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานั้นสามารถกระทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมและเป็นทางปฏิบัติของรัฐส่วนใหญ่ได้แก่การลงนาม (Signature) การแลกเปลี่ยนตราสารสัน (Exchange of instruments) การให้สัตยาบัน (Ratification) การยอมรับ (Acceptance) การให้ความเห็นชอบ (Approval) การภาคยานุวัติ (Accession) นอกจากนั้นการให้ความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาของภาคีของสนธิสัญญา ยังอาจจะกระทำได้โดยวิธีอื่นๆตามที่รัฐภาคีของสนธิสัญญาจะได้ตกลงกัน หรืออาจจะโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเหตุที่การทำสนธิสัญญามีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก จึงไม่ควรที่ไทยจะผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการลงนามเพียงอย่างเดียว สมควรที่จะต้องให้มีการให้สัตยาบันก่อนที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา เพื่อให้โอกาสสังคมไทยได้ศึกษาอย่างรอบคอบในข้อบทของสนธิสัญญาในตัวบทที่ถูกต้องแท้จริงของสนธิสัญญานั้น (Authentic Text) และเป็นโอกาสที่สังคมไทยจะได้รู้อย่างแท้จริงว่าสนธิสัญญา นั้นทำให้สังคมไทยได้ หรือเสียอะไร

การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการให้สัตยาบัน (Ratification) มีความจำเป็นหลายประการ กล่าวคือหลังจากที่รัฐได้เจรจา ตกลง ทำสนธิสัญญาแล้ว และได้รับรองข้อบทในสนธิสัญญา ตลอดจนได้บรรลุข้อบทที่แน่นอนแล้ว (A definitive text) รัฐจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน ก่อนที่จะให้ความยินยอมขั้นสุดท้ายผูกพันรัฐต่อสนธิสัญญา หรือการรับรองขั้นสุดท้าย โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

1. รัฐจะได้มีเวลาในการพิจารณาทบทวนทั้งในส่วนของข้อบทในแต่ละมาตราซึ่งเป็นข้อบทที่แน่นอนแล้วให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง และพิจารณาถึงผลโดยรวมของสนธิสัญญาต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

2. รัฐจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายในของรัฐให้ถูกต้อง เช่น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การทำสนธิสัญญาชนิดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสียก่อน ก็จะต้องดำเนินการไปตามนั้น ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอน กฎระเบียบ หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมี เช่นในบางกรณีหากเป็นสนธิสัญญาที่มีความสำคัญและกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรง รัฐอาจจะต้อง

ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงประชามติ หรือการทำประชาพิจารณ์เพื่อประเมินในผลความผูกพันของรัฐตามสนธิสัญญานั้นๆ ต่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติบ้านเมืองและมวลชน

3. รัฐอาจจะต้องดำเนินการเพื่อออกกฎหมายภายในมารองรับเพื่อให้การปฏิบัติตามสนธิสัญญาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือออกกฎหมายบังคับการให้เป็นไปตามสนธิสัญญานั้นๆ หรือออกกฎหมายอนุวัติการตามสนธิสัญญา เป็นต้น

บทบาทของการให้สัตยาบันคือกระบวนการ หรือขั้นตอนที่กำหนดให้รัฐแสดงเจตนารมณ์ให้ความยินยอมผูกพันรัฐตามสนธิสัญญา ดังนั้นหากในสนธิสัญญาใดที่มีการกำหนดให้ต้องมีการให้สัตยาบันกันก่อน สนธิสัญญาจึงจะผูกพันรัฐนั้น หากรัฐภาคีใดยังไม่ได้ให้สัตยาบัน รัฐนั้นก็ยังไม่ต้องผูกพันตามสนธิสัญญา แม้ว่ารัฐนั้นจะได้ลงนามในสนธิสัญญาแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าสนธิสัญญานั้นไม่มีผลทางกฎหมายเลย การแสดงความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการให้สัตยาบันนั้นต้องกระทำต่อเมื่อ

(ก) สนธิสัญญานั้นกำหนดไว้ว่าการแสดงความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาดังกล่าวให้กระทำโดยการให้สัตยาบัน

(ข) รัฐภาคีซึ่งเจรจาสนธิสัญญานั้นตกลงกันให้ต้องมีการให้สัตยาบัน

(ค) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจซึ่งได้ลงนามในสนธิสัญญานั้น จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการให้สัตยาบันโดยรัฐอีกครั้งหนึ่ง รัฐจึงจะผูกพันตามสนธิสัญญานั้น

(ง) ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจเต็ม Full Powers ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของรัฐว่าการลงนามในสนธิสัญญาของตัวแทนนั้นจะต้องมีการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่ง รัฐจึงจะผูกพันตามสนธิสัญญา หรือในระหว่างที่มีการเจรจากันนั้น รัฐภาคีดังกล่าวได้แสดงเจตนาเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อบทของสนธิสัญญาในกระบวนการให้สัตยาบัน หมายความว่า ข้อบทของสนธิสัญญาที่ได้รับการรับรองแล้ว และยืนยันในความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นเป็นข้อบทที่แน่นอนแล้วของสนธิสัญญา จึงไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อ เป็นเงื่อนไขในการให้สัตยาบัน การให้สัตยาบันจึงเป็นการยืนยันที่รัฐจะให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาที่ตกลงเช่นนั้นแล้ว ดังนั้น หากรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐ หรือรัฐจะเสียเปรียบก็เพียงแต่ไม่ให้สัตยาบันสนธิสัญญานั้นๆ ส่วนการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเพิ่มเติม นั้นจะดำเนินการไปตามที่ภาคีได้ตกลงกันในส่วนของข้อกำหนดว่าด้วย Amendment หรือ Modification ตามที่ตกลงในสนธิสัญญาต่อไปหรือเปิดการเจรจากันใหม่ในส่วนนั้น ถ้าอีกฝ่าย หรือ ภาคีอื่นยินยอมเจรจาด้วย

สนธิสัญญามีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ไม่ใช่ นับตั้งแต่วันที่มีการให้สัตยาบันเว้นแต่ในสนธิสัญญา หรือโดยรัฐภาคีที่เข้าร่วมเจรจาจะกำหนด หรือ ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ขอให้เข้าใจด้วยว่า การเริ่มมีผลบังคับของสนธิสัญญา (Entry into force กับ การผูกพันตามสนธิสัญญา (to be bound by the treaty เป็นคนละกรณีกัน)

การให้สัตยาบันสนธิสัญญาเป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลผู้มีอำนาจในการทำสนธิสัญญา (Treaty-Making Power) กล่าวคือประมุขของรัฐ หรือ รัฐบาล จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น หากเป็นสนธิสัญญาที่ต้องผ่านการอนุมัติ เห็นชอบ หรือผ่านการพิจารณาของสภา ก็ต้องดำเนินการตามนั้นให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะให้สัตยาบันได้ ดังนั้นการแสดงเจตนาให้สัตยาบันโดยไม่ผ่านกระบวนการดังกล่าวก็ทำให้การให้สัตยาบันไม่มีผลตามกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตระหนักให้ดี

ความผูกพันตามสนธิสัญญาต่อรัฐนี้ เป็นความผูกพันที่มีอยู่เหนือดินแดนทั้งหมดของรัฐที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ หลักสนธิสัญญาไม่มีผลย้อนหลัง (Non-Retroactivity of Treaty) ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปที่ใช้กับการกระทำทางกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ เว้นแต่จะปรากฏเจตนาเป็นอย่างอื่นแตกต่างไปจากที่ปรากฏในสนธิสัญญา หรือปรากฏเป็นกรณีอย่างอื่น บทบัญญัติต่างๆของสนธิสัญญาย่อมไม่ผูกพันภาคีของสนธิสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สนธิสัญญามีผลใช้บังคับต่อภาคีของสนธิสัญญานั้น หรือสถานการณ์ซึ่งได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่สนธิสัญญามีผล

สำหรับลักษณะความผูกพันของสนธิสัญญาในกฎหมายภายในนั้น เมื่อสนธิสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว รัฐภาคีจะต้องผูกพันตามบทบัญญัติของสนธิสัญญา และเนื่องจากการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญานี้ครอบคลุมถึงองค์กรต่างๆของรัฐทั้งหมดในฐานะที่องค์กรเหล่านี้ต้องทำหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามสนธิสัญญา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายภายในมารองรับบังคับการให้เป็นไปตามผลของสนธิสัญญานั้นๆ ซึ่งมีวิธีการต่างๆ เช่นออกพระราชบัญญัติมารองรับสนธิสัญญา การออกกฎหมายให้เป็นไปตามสนธิสัญญา หรือ การนำข้อบทในสนธิสัญญามา ตราเป็นกฎหมาย เป็นต้น

สิ่งที่พึงจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบคือการตั้งข้อสงวนในสนธิสัญญาในส่วนที่ไทยไม่ประสงค์ที่จะต้องผูกพันตามสนธิสัญญา ข้อกำหนดในการที่สนธิสัญญาเริ่มมีผลบังคับ (Entry into force) การแก้ไขเพิ่มเติม (Amendment) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Modification) การบอกเลิกสนธิสัญญา (Termination) หรือความสิ้นผลของสนธิสัญญา และข้อกำหนด Carve out, non-conforming, Exception ในกรณีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง General exception ที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะด้านต่างๆ ความมั่นคงแห่งชาติ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และ แกนแห่งอำนาจอธิปไตยของรัฐ (Core Sovereignty)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำสนธิสัญญา ว่านักศึกษามีความเข้าใจขั้นตอนต่างๆในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษาสามารถ พิจารณา และ วิเคราะห์ กระบวนการทำสนธิสัญญาของประเทศไทยในปัจจุบันได้ เนื่องจาก ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้ตกลงทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศจำนวนมาก ทั้งที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และ ความเป็นอยู่ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ การที่นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการทำสนธิสัญญา ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ การทำสนธิสัญญาเหล่านี้ได้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เมื่อจะต้องปฏิบัติตาม

สนธิสัญญาที่ได้กระทำขึ้น และในแง่ของกระบวนการตามกฎหมายไทย เช่นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 190 หากจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ หรือ การทำประชามติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในการศึกษา ข้อดี ข้อเสีย และ ความถูกต้องในกระบวนการต่างๆของการทำสนธิสัญญาได้

กฎหมายระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ การทำข้อสอบของนักศึกษาในข้อนี้ หากได้ศึกษามาอย่างดีแล้วจะสามารถทำข้อสอบได้อธิบายขั้นตอนต่างๆได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากขั้นตอนเหล่านี้ได้อธิบายตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สามารถเข้าใจได้โดยไม่ยาก หากนักศึกษาไม่ได้ศึกษามากก็ไม่สามารถตอบได้ถูกต้อง จึงแนะนำให้นักศึกษาหมั่นศึกษา เล่าเรียน คิด และ พินิจระหัดให้ถ้วนถี่เมื่อได้ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศในแต่ละหน่วย นักศึกษาก็จะสามารถทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี